

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ก็มีได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้คำประกันจะกลายเป็นลูกหนี้ชั้นต้นเช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีสิทธิในฐานะผู้คำประกันตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดิม จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๐/๒๕๕๐)

#### ๑.๒. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครอง

สัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่เกิดจากการตกลงร่วมกัน แต่ฝ่ายปกครองจะกำหนดเนื้อหาหลักๆ ของสัญญาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายปกครองมักจะเป็นผู้กำหนดถึงวิธีการในการจัดทำสัญญาและข้อกำหนดในสัญญาที่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา นอกจากเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่เป็นส่วนสำคัญของสัญญาทางปกครองแล้วกฎหมายทั้งระดับที่เป็นกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ และกฎหมายระดับที่เป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารก็มีส่วนสำคัญในการบัญญัติถึง “ข้อกำหนด” ต่างๆ ในสัญญาด้วย<sup>๒๐</sup> กล่าวคือ ฝ่ายปกครองต้องจัดทำสัญญาแต่ละประเภทตามที่กฎหมายได้บัญญัติขั้นตอนและเนื้อหาสาระไว้ แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาเองก็มีสิทธิที่จะกำหนดข้อความต่างๆ ไว้ในสัญญาได้หากไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่บังคับว่าต้องมีในสัญญาหรือข้อกำหนดที่ห้ามมิในสัญญาเพื่อที่จะให้สัญญามีสภาพในทางกฎหมาย อันได้แก่ ข้อกำหนดที่แสดงถึงความมีอยู่ของสัญญา โดยสัญญาทางปกครองนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดและเฉพาะเจาะจง รวมทั้งจะต้องมีระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอนด้วย และหากเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทนหรือค่าบริการก็ต้องกำหนดเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่บังคับว่าต้องมีในสัญญายังประกอบด้วยข้อกำหนดที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีเพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของนิติบุคคลจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญาด้วย เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าทดแทนความเสียหายจากการเลิกสัญญา เป็นต้น รวมทั้งคือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลมาจากเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและเป็นเอกสารที่ระบุถึงเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ เช่น สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา เป็นต้น นอกจากข้อกำหนดที่บังคับว่าต้องมีในสัญญาแล้ว

<sup>๒๐</sup> นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, หน้า ๓๖๔-๓๘๙.



คู่สัญญายังมีสิทธิที่จะกำหนดข้อความต่าง ๆ ในสัญญาได้หากไม่ใช่ข้อกำหนดที่ห้ามมีในสัญญา เช่น ข้อกำหนดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญานั้น คู่สัญญาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาได้โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรื่องระยะเวลา เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้นคู่สัญญาต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขพอสมควร เพราะการแก้ไขนั้นอาจมีผลทำให้เกิดเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมา และอาจถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยหลักที่จะใช้ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ ต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของสัญญาและผลทางกฎหมายของสัญญาว่าเหมือนหรือแตกต่างจากสัญญาเดิมอย่างไรด้วย ซึ่งในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับการมีผลผูกพันของสัญญาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไว้หลายกรณี ดังต่อไปนี้

#### ๑.๒.๑ การมีผลผูกพันของข้อสัญญาที่เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองโดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการ

จากที่กล่าวไปแล้วว่าในระหว่างการดำเนินการตามสัญญานั้น คู่สัญญาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาได้โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญาสมัครใจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองที่ได้จัดทำไว้แล้ว แม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ ข้อสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก็ย่อมมีผลผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตามด้วย ดังคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ต่อไปนี้

๑) การที่ผู้แทนของหน่วยงานทางปกครองทำข้อตกลงเพิ่มเติมด้วยวาจาให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยงานดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา และมีได้เกิดจากการสมยอมกันระหว่างผู้แทนของหน่วยงานทางปกครองกับผู้รับจ้าง หรือเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างต้องการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา



**ย่อมมีผลผูกพันให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างอันเกิดจากการทำงานดังกล่าว**

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนคลองขององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชำระค่าจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง อันเนื่องมาจากการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง เพื่อให้การก่อสร้างถนนตามสัญญาสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุที่ระหว่างการก่อสร้างถนนได้เกิดการทรุดตัวของดินด้านข้างถนนไหลเลื่อนลงคลองซึ่งจะทำให้ถนนชำรุดเสียหาย นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การสั่งการของประธานกรรมการบริหารฯ เป็นการสั่งที่มีอำนาจกระทำได้ โดยถือว่าเป็นงานพิเศษซึ่งอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้สามารถก่อสร้างถนนตามสัญญาต่อไปได้ และถือว่าการสร้างเชื่อมเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้างถนน แม้เป็นการตกลงด้วยวาจากก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘๗<sup>๒๑</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้บัญญัติให้สัญญาจ้างทำของต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อกรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการสมยอมกันระหว่างผู้แทนของหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างหรือเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างต้องการหลีกเลี่ยงการประกวดราคา แม้จะเป็นกรณีที่มิได้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่โดยที่การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่อาจนำการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ มาเป็นเหตุผลปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมตามที่มีการสั่งให้ทำเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับชำระค่าจ้างเป็นการตอบแทนตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๔๗)

<sup>๒๑</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น



๒) เมื่อคู่สัญญาทางปกครองตกลงกันแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาทางปกครองฉบับเดิมโดยสุจริตด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาจึงต้องผูกพันตามข้อสัญญาที่แก้ไขใหม่และไม่อาจกล่าวอ้างประโยชน์ตามข้อสัญญาเดิมเพื่อปฏิเสธการปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ในคดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้ก่อสร้างอาคารหอพักข้าราชการ โดยในประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้บังคับกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเดิมเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) อันเป็นการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แต่เมื่องานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งความเห็นจากสำนักงานประมาณว่าสัญญาจ้างข้างต้นไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินชดเชยเนื่องจากในประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้บังคับ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นการดำเนินการโดยสุจริตด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างจึงเป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตามแม้ว่าในประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจะไม่ได้ระบุให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ก็ตาม ประกอบกับในการตกลงยินยอมให้จัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเพื่อนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า ณ เวลาที่แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีการระบุไว้ในประกาศประกวดราคามาตั้งแต่ต้นว่าจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ นอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐย่อมเข้าใจเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีได้ดีกว่าผู้ฟ้องคดี หรือหากยังเข้าใจไม่ชัดเจนก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำจากสำนักงานประมาณในฐานะที่เป็นหน่วยงาน



ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้เสียก่อนที่จะลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) โดยอ้างว่าในประกาศประกวดราคาไม่ได้ระบุให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มิได้พิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๔๙)

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเพื่อให้ครอบคลุมถึงการขยายระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญาเดิม อันมีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่คู่สัญญาจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมการขยายระยะเวลาตามสัญญาเดิม อันมีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวนั้น มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าววินิจฉัยต่อไป

กรณีที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาการศึกษาและแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำสัญญากับผู้รับทุนขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายออกไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาหรือสาระสำคัญอื่นที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากคำขอของฝ่ายผู้รับทุน (ผู้ให้สัญญา) จึงไม่มีเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือภาระผูกพันอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้สัญญา นอกจากนี้ หากมิได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ สัญญาฉบับเดิมจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้นำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้รับสัญญา ผู้ให้สัญญา มีหน้าที่สำคัญเพียงลงนามในสัญญาเท่านั้น การทำสัญญาขึ้นใหม่จึงไม่ใช่การสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ให้สัญญาเกินสมควร

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ลาศึกษาในระดับปริญญาโท



ณ ต่างประเทศ มีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งในระหว่างการศึกษาผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษารวมทั้งหมดสามครั้ง ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้รายงานตัวเข้ารับราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีและได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเพิ่มเติมทุกครั้งที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว.๒๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ โดยหนังสือดังกล่าวได้กำหนดให้ใช้แบบสัญญาในข้อ ๑ วรรคสองว่า ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกำหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทำสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญานับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อสัญญาเดิมมีความสมบูรณ์อยู่แล้ว การจัดทำสัญญาขึ้นใหม่จึงเป็นการกระทำที่ซ้ำซ้อนและไม่มีความจำเป็น และหากสัญญาที่จัดทำขึ้นใหม่มีสาระแห่งความผูกพันคู่สัญญาแตกต่างจากสัญญาเดิมย่อมไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญา จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำสัญญาเพิ่มเติมนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การจัดทำสัญญาขึ้นใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาหรือสาระสำคัญอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากคำขอของฝ่ายผู้รับทุน (ผู้ให้สัญญาทั้งสิ้น) จึงไม่มีเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือภาระผูกพันอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้สัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และหากมิได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่สัญญานับเดิมจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เนื่องจากหากมิได้มีการนำหลักฐานอื่นมาประกอบเพิ่มเติม อาจก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนและอาจนำไปสู่การโต้แย้ง ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการฟ้องร้องต่อศาลและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาในภายหลังได้ การจัดทำสัญญาใหม่ให้ชัดเจนจึงเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาด้วยกันทุกฝ่าย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน



ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำสัญญาใหม่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้รับสัญญา ผู้ให้สัญญามีหน้าที่สำคัญเพียงลงนามในสัญญาเท่านั้น จึงมิได้เป็นการกระทำที่เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับผู้ให้สัญญาเกินสมควรแต่ประการใด การที่สัญญาข้อ ๑ วรรคสอง ตอนท้ายมีข้อความว่า หากมิได้มีการจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าสัญญานับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วยนั้น เป็นการเขียนเพื่อแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ให้สัญญากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยมิได้จัดทำสัญญาขึ้นใหม่ มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าตนเองไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการในช่วงเวลาที่ได้มีการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หรือเป็นกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดทำสัญญาขึ้นใหม่ได้ ข้อสัญญาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๕/๒๕๕๐)

**๑.๒.๒ การมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ**

สำหรับการมีผลผูกพันของสัญญาทางปกครองที่เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินั้น มีกรณีตัวอย่าง เช่น สัญญาร่วมทุนเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนที่จะเข้าจัดทำบริการสาธารณะร่วมกัน การดำเนินการร่วมทุนกับเอกชนในกรณีดังกล่าวก็ต้องจัดทำเป็นสัญญาเช่นเดียวกันกับสัญญาทางปกครองประเภทอื่นๆ<sup>๒๒</sup> โดยเรียกว่าสัญญาโครงการร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำสัญญาของรัฐโปร่งใสควบคุมได้และป้องกัน

<sup>๒๒</sup> นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, หน้า ๑๕๐.





การทุจริต กฎหมายจึงได้พยายามให้มีการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ในขั้นตอนของการประกาศเชิญชวนไปจนกระทั่งถึงการลงนามในสัญญา<sup>๒๓</sup> ซึ่งที่ผ่านมานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีคำวินิจฉัยในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทางปกครองที่เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะโดยไม่ได้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ ข้างต้น ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตาม ดังปรากฏตามคำวินิจฉัยต่อไปนี้

การจัดทำสัญญาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะในกิจการที่มีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบก่อนมีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๑<sup>๒๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่เช่นนั้น ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย

<sup>๒๓</sup> บุปผา อัครพิมาน, สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย, หน้า ๑๑๙.

<sup>๒๔</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานและดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งเป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นเกินสามคน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ





ในคดีที่คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีวิทย์โทรทัศน์ และดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งขึ้น ตามมาตรา ๑๓<sup>๒๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้าร่วมงานและดำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้จัดทำร่างสัญญา เข้าร่วมงานและดำเนินการวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ให้ความเห็นชอบ การคัดเลือกดังกล่าว และให้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนลงนาม ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ร้องขอให้เพิ่มเติมข้อสัญญาโดยให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิด เจริญเพื่อแก้ไขสัญญาได้ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้เพิ่มเติมข้อสัญญาในเรื่องดังกล่าว ไว้ในร่างสัญญาข้อ ๕ วรรคสี่ และส่งร่างสัญญาที่มีการแก้ไขแล้วไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ และในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา เข้าร่วมงานและดำเนินการวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีได้เสนอ ร่างสัญญาส่วนที่เพิ่มเติมข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ สัญญา ฉบับพิพาทมีสาระสำคัญกำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องนำเสนอรายการ ประเภทข่าว สารคดี และสารประโยชน์ร่วมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของเวลาออกอากาศ ทั้งหมด และช่วงเวลาระหว่าง ๑๙ นาฬิกา ถึง ๒๑.๓๐ นาฬิกา (Prime Time) จะต้องใช้

---

<sup>๒๕</sup> พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานและดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการนำผลการคัดเลือกพร้อมเหตุผล ประเด็นที่เจรจาต่อรอง เรื่องผลประโยชน์ของรัฐ ร่างสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน

หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น แล้วนำผลการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด



สำหรับรายการประเภทดังกล่าวเท่านั้น และในข้อ ๑๕ ได้กำหนดถึงข้อตกลงของคู่สัญญาที่จะรับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ สำหรับข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้เพิ่มเติมข้อสัญญาเกี่ยวกับการเปิดเจรจาเพื่อให้แก้ไขสัญญาได้ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อ ๕ วรรคสี่ ของสัญญานั้นระบุว่า หลังจากวันทำสัญญา หากผู้ฟ้องคดีหรือหน่วยงานของรัฐให้สัมปทาน อนุญาต หรือทำสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นเข้าดำเนินกิจการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์โดยมีการโฆษณา หรืออนุญาตให้โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบิลทีวี) ทำการโฆษณาได้ และเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างรุนแรง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจะพิจารณาและเจรจากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยเร็วเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากผลกระทบดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอให้พิจารณาหามาตรการชดเชยความเสียหายให้ตามนัยข้อ ๕ วรรคสี่ ดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้เอกชนรายอื่นประกอบกิจการในลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างรุนแรง โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีปรับลดค่าสัมปทานและพิจารณาแก้ไขสัญญาโดยยกเลิกข้อกำหนดในเรื่องสัดส่วนเนื้อหาสาระของรายการและข้อจำกัดเรื่องผังรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีพิจารณาเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ฟ้องคดี จึงได้เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนและปรับลดสัดส่วนการเสนอรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ รวมทั้งสามารถออกอากาศในช่วงเวลา Prime Time ได้โดยไม่ถูกจำกัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุโทรทัศน์ เป็นทรัพยากรสื่อสารของรัฐที่รัฐต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน การจัดให้มีสถานีวิทยุโทรทัศน์และดำเนินการส่งวิทยุโทรทัศน์จึงเป็นบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐอาจเป็นผู้จัดทำเอง หรือมอบหมายให้เอกชนเป็น



ผู้จัดทำแทน หรือให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะโดยวิธีการให้สัมปทานแก่เอกชน ดังนั้น สัญญาที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะจึงเป็นสัญญาระหว่างรัฐผู้ให้สัมปทานกับเอกชนผู้รับสัมปทาน โดยมีประชาชนผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และหากเอกชนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารจึงต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยมีการกำหนดให้การให้สัมปทานหรือการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐที่มีการลงทุนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ซึ่งการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเป็นเพียงผู้เตรียมการและเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในระดับปฏิบัติการเท่านั้น ส่วนอำนาจการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนของการให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการและขั้นตอนการให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนที่จะเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารที่จะต้องใช้อำนาจดังกล่าวแทนรัฐ สำหรับสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นสัญญาที่รัฐให้สัมปทานในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์และดำเนินการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ แต่รัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการโดยวิธีให้สัมปทานแก่เอกชนโดยมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการรายงานผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานหรือดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งจัดทำร่างสัญญาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ และสั่งการให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่างสัญญาก่อนที่จะมีการลงนามต่อไป ดังนั้น ร่างสัญญาที่จะมีการลงนามจึงต้องเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ แต่เมื่อพิเคราะห์ข้อสัญญาในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอเพิ่มเติมภายหลังจากการที่ได้รับการคัดเลือกและก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาแล้ว จะเห็นได้ว่า



มีเนื้อหาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากหลักการตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นไว้ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอเพิ่มเติมข้อสัญญาภายหลังจากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานหรือดำเนินการตามโครงการแล้ว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา รายอื่น นอกจากนั้น เนื้อหาที่เพิ่มเติมยังเป็นการกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคู่สัญญาแทนรัฐ ต้องผูกพันตนและรับผิดชอบแทนหน่วยงานอื่นของรัฐในอันที่จะไม่ให้สัมปทาน อนุญาต หรือทำสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นที่จะเข้าดำเนินการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์โดยมีการโฆษณา หรือ อนุญาตให้โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทำการโฆษณาได้ ซึ่งการเพิ่มเติมข้อสัญญา ดังกล่าวเป็นการเกินอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่เป็นเพียงหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่มีอำนาจเหนือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยหากจะให้ข้อสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องให้คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาฯ ซึ่งมีการเพิ่มเติมข้อ ๕ วรรคสี่ ของสัญญาไว้แล้ว โดยไม่ได้เสนอการขอเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นการเพิ่มเติมที่ขัดต่อมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานและดำเนินการในกิจการของรัฐฯ ดังนั้น สัญญาฯ ข้อ ๕ วรรคสี่ จึงไม่มีผลผูกพันรัฐตามกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่อาจมีคำชี้ขาดว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาฯ ในข้อ ๕ วรรคสี่ ดังกล่าว ประกอบกับการที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถออกอากาศในช่วงเวลา Prime Time ได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์เท่านั้น รวมทั้งให้ปรับสัดส่วนการเสนอรายการต่างๆ ดังกล่าวจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนั้น เป็นการแก้ไขสาระของสัญญาฯ ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ อันเป็นข้อสัญญาที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะ และเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์นี้ขึ้นมา คำชี้ขาดดังกล่าวจึงมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของรัฐ มิใช่อยู่ในอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ปรากฏต่อศาลว่าการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม



